

1500933-02.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALBIERI

Comarca: Nova Granada

Foro: Foro de Nova Granada

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... (responde a processos criminais por tráfico de drogas - fls. 67 - e possui condenação em razão da prática do delito previsto no artigo 12 da Lei nº 6368/76 revogada pela Lei nº 11.343/06), demonstram que era ela (a droga) destinada ao consumo de terceiros, e não próprio. Assim, caracterizado o crime de tráfico. Além disso, foi constatada através de perícia realizada no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nova Granada

Foro de Nova Granada - Vara Única

Av. Dr. Hildeberto de Albuquerque Ferreira, nº 1001, Centro

Nova Granada-SP - cep 15440-000

Processo nº 1500933-02.2022.8.26.0559 - p.

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500933-02.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145625/2022 - DEL.POL.NOVA GRANADA/SP,

25248254 - DEL.POL.NOVA GRANADA/SP

Autor:

Promotora de Justiça:

Justiça Pública

Vanessa Ibarreche Santa Terra - presente

Réu:

Advogado:

Emerson Lorenzi - presente

Mateus Alípio Galera - OAB/SP 329.376 - presente

Testemunhas Comum:

Testemunhas de Defesa:

Fernando Christofolo - presente

Alessandro Christofolo - presente

Márcia Maria da Silva - presente

Giovana Cristina Fernandes Fernandes - presente

Angela Pereira da Silva - presente

Artigo da Denúncia:

Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06

Data da Audiência:
13/10/2022 às 13:00h
Réu Preso

Aos 13 de outubro de 2022, às 13:00 horas, na Vara Única do Foro de Nova Granada, Comarca de Nova Granada, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. GABRIEL ALBIERI, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, através de Audiência realizada por meio virtual, utilizando a ferramenta 'Microsoft Teams', nos termos do Provimento CSM nº 2.651/2022 e Comunicado CGJ nº 284/2020. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, houve os comparecimentos acima. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas 02 (duas) testemunhas comum, 02 (duas) testemunhas de defesa e interrogado o acusado, após entrevista reservada com seu defensor. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, sendo que o arquivo com a gravação da audiência será salvo no Sistema e-SAJ, com disponibilização imediata para as partes por meio de certidão ou termo juntada nos autos após a audiência. O defensor do réu solicitou a desistência de oitiva da testemunha de defesa: Márcia Maria da Silva. Pelo MM. Juiz foi homologada a desistência e dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal e determinou que as partes se manifestassem em debates. Por primeiro foi conferida a palavra à Promotora de Justiça e depois ao Defensor do réu que se manifestaram pelo sistema de gravação audiovisual pelo aplicativo 'Microsoft Teams'. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. Trata-se de ação penal pública incondicionada, sob o rito ordinário, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor de ÉMERSON LORENZI, devidamente qualificado nos autos (fls. 16/17), em decorrência da suposta prática do delito capitulado no art. 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06, nos termos descritos na denúncia. Nos termos do artigo 12 do CPP, acompanhou a denúncia (fls. 167/169) o inquérito policial, onde foram encadernadas, dentre outras peças, o auto de prisão em flagrante (fl. 1), termo de depoimento dos policiais militares (fls. 2/4), interrogatório do acusado (fl. 5), boletim de ocorrência (fls. 6/8), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), laudo pericial de constatação preliminar do entorpecente (fls. 11/13), comprovante de depósito do valor em dinheiro apreendido (fl. 147), auto de arrecadação dos demais objetos apreendidos (fl. 148), laudo pericial definitivo do entorpecente (fls. 150/152), relação de remessa do aparelho celular e dos objetos apreendidos (fl. 157) e o relatório final do inquérito policial (fls. 159/161). Foi realizada a audiência de custódia (fls. 123/125), ocasião em que se homologou o flagrante e decretou-se a prisão preventiva do acusado ÉMERSON LORENZI. Na mesma solenidade foi autorizada a destruição da droga apreendida. Além disso, foi expedido e cumprido o mandado de prisão (fls. 126/127 e 132/133). Oferecida e recebida a denúncia (fls. 167/169 e 171/176). Determinou-se a citação do acusado para apresentação de sua resposta à acusação. Na mesma ocasião foi autorizado aos peritos o acesso ao conteúdo do aparelho celular apreendido, assim como deferiu-se a busca e apreensão do veículo utilizado para o transporte de drogas (fls. 171/176). O acusado foi citado (fl. 208). Por meio de defensor constituído (fl. 282), o acusado impetrou Habeas Corpus, requerendo, liminarmente, a conversão da prisão preventiva em concessão de liberdade, alegando nulidade na decisão por falta de fundamentação idônea ou, subsidiariamente, seja concedida a prisão domiciliar ao réu (fls. 211/230). Ao ser analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a liminar foi indeferida (fls. 231/233). Acostado aos autos o laudo pericial do aparelho celular apreendido (fls. 248/257). A defesa do acusado apresentou resposta à acusação (fls. 258/281), requerendo, preliminarmente, a inépcia da denúncia e o seu não recebimento; a nulidade do flagrante por ilegalidade da busca pessoal; assim como a justiça gratuita ao acusado. Além disso, requereu também a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o uso de entorpecentes; a

instauração de incidente de verificação de dependência toxicológica; e que seja disponibilizado o trajeto do GPS que fica na viatura policial, da data e horário da ocorrência. O Ministério Público se manifestou, discordando do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa (fls. 288/292). Em decisão de fls. 293/295, não foi reconhecida a inépcia da denúncia, sendo mantido o seu recebimento, assim como foi indeferido o pedido de realização de exame toxicológico em relação ao acusado. Constatou-se, ainda, na decisão, que não há o que se falar quanto ao relaxamento da prisão em flagrante, tendo em vista que o flagrante já foi homologado em audiência de custódia; e, quanto à disponibilização das informações do GPS, também se considerou inviável, contando com o fato de que os policiais poderiam ser questionados, pessoalmente, sobre o trajeto da viatura, quando fossem prestar seus depoimentos em juízo. Na mesma decisão foi: indeferido o pedido de absolvição sumária, vez que ausentes qualquer das hipóteses dos artigos 395 a 397 do Código de Processo Penal; a prisão preventiva do acusado foi reavaliada, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP, sendo mantida; e designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 13 de outubro de 2022, às 13h. Juntado aos autos relatório de investigação quanto não apreensão do veículo CHEVROLET/CORSA, placa CAC-1778, utilizado para o transporte de drogas (fls. 357/380). O Ministério Público manifestou-se requerendo que seja oficiado ao órgão de trânsito para que conste o gravame de apreensão do veículo, a fim de que, ao ser abordado, ele seja apreendido (fl. 384). Em audiência virtual realizada, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e duas testemunhas pela defesa, bem como o Réu foi interrogado. Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. É o relatório, no essencial. Passo a fundamentar e a decidir. Antes de enfrentar o mérito, necessário analisar as preliminares levantadas pela defesa. Compulsando os autos, não há que se falar em nulidade do flagrante em decorrência da ilegalidade da busca pessoal. Primeiro porque o flagrante foi homologado pelo juízo da custódia e, em segundo lugar, houve justa causa para ação policial. Conforme relatado pelos policiais em audiência, o acusado Emerson conduzia o seu veículo e, quando passou próximo à viatura policial, os policiais deram ordem de parada ao acusado, cientes de que o veículo por ele pilotado era alvo de denúncias relacionadas ao 'disque-droga'. O Réu desobedeceu a ordem de parada e empreendeu em fuga. Presente, portanto, a justa causa a autorizar a abordagem policial. Inexistindo questões preliminares e/ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, ou mesmo nulidades que possam macular os atos e os processos como um todo, as questões trazidas a juízo merecem um provimento jurisdicional de cunho material. Cuida-se de ação penal pública incondicionada que atribui ao acusado a prática do crime previsto no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06. O 'caput' do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 contempla 18 núcleos, tratando-se de tipo misto alternativo, ou seja, ainda que o agente pratique mais de um núcleo, a ele será imputado apenas um delito. Além disso, da leitura do mencionado dispositivo conclui-se que a traficância pode ocorrer ainda que gratuitamente, mas desde que a conduta seja praticada sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O tipo subjetivo consiste no dolo (vontade consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública. A materialidade do delito corresponde a prova de sua existência. No caso dos autos, a materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), termo de depoimento dos policiais militares (fls. 2/4), interrogatório do acusado (fl. 5), boletim de ocorrência (fls. 6/8), apreensão da substância entorpecente em poder do réu, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), laudo pericial de constatação preliminar do entorpecente, identificado como cocaína (fls. 11/13), comprovante de depósito do valor em dinheiro apreendido (fl. 147), auto de arrecadação dos demais objetos apreendidos (fl. 148), laudo pericial definitivo do entorpecente (fls. 150/152), relação de remessa do aparelho celular e dos objetos apreendidos (fl. 157) e o relatório final do inquérito policial (fls. 159/161). Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito

criminal, o que ocorreu in casu. As substâncias apreendidas foram identificadas pelos peritos como cocaína, definida como droga pelo art. 66 da Lei nº 11.343/2006 e pela Portaria SVS/MS nº 344/1998. Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado ÉMERSON LORENZI foi o autor do crime de tráfico de drogas narrado na denúncia. Ouvida em Juízo, a testemunha, o policial militar Alessandro Christofolo, disse que estava realizando patrulhamento pelas ruas desta cidade. No cruzamento com a Rua José Barone Mercadante, o veículo do acusado fez a conversão e seguiu no mesmo sentido que a viatura. Informa que no momento da conversão reconheceu Emerson, também conhecido como 'véio', sendo que já era de conhecimento dos policiais que Emerson tem a fama de ser comerciante de entorpecentes

por 'disque entrega'. Deram sinal de parada para realizarem a abordagem. O acusado não respeitou a ordem de parada, deslocando-se o automóvel por aproximadamente 04 quarteirões, em perseguição, até que Emerson parou o veículo. Antes da parada, visualizaram Emerson arremessando um tubo para fora do veículo. Logo que parou o veículo em definitivo, o Réu arremessou um estojo de lente também para fora do veículo. Durante a revista no automóvel e pessoal, nada foi encontrado de ilícito no veículo, entretanto, no bolso da calça, que ficava na frente e do lado direito de Emerson, foi localizado a quantia de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) em diversas notas repartidas. Quando o veículo parou, o acusado jogou para fora um estojo de lente que foi localizado e em seu interior havia duas pedras de craque amarelas, que foram apreendidas. Em seguida depoente retornou ao local em que foi arremessado o tubo alaranjando e localizou-o contendo em seu interior mais 16 pedras brancas conhecidas por 'crack'. Quando estavam no interior da delegacia, o telefone celular do acusado tocava várias vezes com números diferentes. Em mesmos termos foram as declarações de seu colega, Fernando Christofolo. Disse que estava trafegando pelas ruas de Nova Granada/SP. Informa que, em dado momento, reconheceu Emerson, conhecido como 'véio', conduzido o seu veículo, sendo que já era de conhecimento dos policiais que Emerson realizava o tráfico de drogas nessa cidade. Deram sinal de parada, o qual não foi respeitado, deslocando-se por aproximadamente 04 quarteirões, até que Emerson parou o veículo. Visualizaram quando Emerson arremessou um tubo alaranjado para fora do veículo, parando em seguida e arremessando um estojo de lente, também para fora do veículo. Durante a revista no automóvel e pessoal foi localizado a quantia de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) em diversas notas. O depoente retornou ao local em que foi arremessado o tubo alaranjando e localizou-o contendo em seu interior pedras de 'crack'. A testemunha de defesa, Giovana Cristina Fernandes, disse que não estava com o acusado no dia dos fatos e nem o viu nesse mesmo dia. Conhece Emerson há uns dois anos. Que a depoente saiba, o acusado não vendia drogas, mas apenas usava crack e cocaína. No dia que ele foi preso, tinha uma 'festinha', mas o acusado não chegou a ir porque foi preso antes. Nessas festinhas, o acusado sempre ficava bem alegre, nervoso e elétrico. A testemunha de defesa, Ângela Pereira da Silva, disse que estava com o acusado antes dele ser preso. O acusado saiu de casa dizendo que ia até um amigo, mas não retornou. Depois, o delegado ligou para a depoente informando que ele havia sido preso. Narra que o acusado consumia drogas, como crack e cocaína. O acusado não tinha emprego fixo. O réu ia para São José do Rio Preto/SP fazer os negócios e, de lá, sempre retornava com dinheiro e assim a casa era mantida financeiramente. Interrogado o acusado, Emerson Lorenzi, negou a prática do delito de tráfico conforme narrado na denúncia. Disse que, na manhã daquele dia, foi para São José do Rio Preto/SP pegar um dinheiro, almoçou com a sua mãe e, a tarde, foi para a zona, onde adquiriu a droga. Na sequência, retornou para Nova Granada/SP. Ficou em casa um tempo com a sua então companheira e decidiu sair para comprar um remédio, derivado do 'viagra', e depois ia a uma festinha. No trajeto até a farmácia, foi abordado pelos policiais, os quais lhe seguiam. Na perseguição, com medo, jogou um pote para a fora do carro. Foi mal educado com os policiais. Não vende droga, mas apenas é usuário. Não reconhece as mensagens de fls. 253. Com efeito, as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar um juízo condenatório. Inicialmente, destaque-se que as testemunhas

arroladas pela defesa em nada enfraqueceram as provas acusatórias. Aliás, merece maior crédito a narrativa policial, desprovida de incoerências e de suspeita de interesse dos milicianos na causa (não há razão para acusarem injustamente o réu). Não há motivos para invalidar o depoimento dos policiais ouvidos em juízo. Destaca-se que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais. Logo, fica claro que todos têm a obrigação de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha, excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e artigo 207, ambos do Código de Processo Penal. Neste sentido, não há motivo para excluir-se o depoimento prestado por agente público. Aliás, como servidor público que é, tem na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES MEIRELLES (Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995). Portanto, não se pode excluir o depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para averiguar-se sua validade. Por tais motivos, o depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não foram contraditadas, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório. Nesse diapasão, há posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações"- STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006. O Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.CONDENACÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO.CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. 2. Concluindo a instância ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, que a acusada praticou tráfico de drogas, porquanto foi vista entregando a sacola com maconha e cocaína ao corréu preso em flagrante, o alcance de entendimento diverso implica no revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 3. Na linha do entendimento esposado por reiterados precedentes deste Tribunal, é permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena-base a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Precedentes. 4. Não caracteriza bis in idem a utilização das circunstâncias da quantidade ou natureza da droga na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, nos casos em que a instância ordinária tenha fundamentado a negativa da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em outras circunstâncias concretas, sendo imprópria a via do habeas corpus à revisão do entendimento. 5. Estabelecidas as penas acima de 5 anos de reclusão e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível a aplicação do regime inicial fechado, imediatamente mais grave que o correspondente ao quantum da sanção aplicada, nos exatos termos do art. 33, § 2º, a, e § 3º, do CP. 6. Ordem denegada. (HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – grifou-se. Diferente não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Apelação – Furto qualificado tentado – Condenação –Recurso da defesa – Pedido de absolvição por

falta de provas e pela incidência do princípio da insignificância - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova oral harmônica e coesa - Palavra da vítima goza de especial relevância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade - Depoimento policial constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade - Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pelas declarações da vítima e, especialmente, pelo laudo pericial - Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância - Ausência de previsão legal - Afronta ao direito fundamental de propriedade - Cabimento do "furto privilegiado", desde que preenchidos os requisitos legais - Pleito de redução da fração de aumento empregada em virtude da agravante da reincidência (de 1/3 para 1/6) - Descabimento - Reincidência específica autoriza incremento maior que 1/6 - Requerimento de aplicação da fração máxima de diminuição cabível pela tentativa (2/3) - Inviabilidade - "Iter criminis" percorrido pelo agente - Proximidade da consumação - Pedidos de modificação do regime inicial semiaberto para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Reincidência específica - Recurso não provido - Erro material da sentença - Promovida a correção da capitulação jurídica do fato - (TJSP;

Apelação Criminal 0006797-66.2015.8.26.0066; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021) (grifos acrescidos). APELAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. Artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Preliminar. Alegação de ausência do laudo de exame de corpo de delito. Crime que deixa vestígios. Nulidade não reconhecida. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunhos de agentes policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Circunstâncias da investitura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Condenação mantida. Dosimetria da pena que, entretanto, comporta reparo. Maus antecedentes descaracterizados. A utilização de condenações pretéritas registradas há mais de quatorze anos em desfavor do condenado contrapõe-se à proposta legislativa que fundamenta o próprio sistema de penas, não se reputando legítima a delonga de um desvalor social superado pelo réu criminalmente reabilitado. Reincidência descaracterizada. Documento que não traz informação acerca do trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa. Pena reduzida ao mínimo legal. Regime inicial de cumprimento abrandado para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Restituição de bens e valores apreendidos. Impossibilidade. Objetos que interessam à persecução penal. Incidência dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500083-83.2019.8.26.0548; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020) (grifos acrescidos). Além disso, a versão do réu está desamparada de qualquer outra prova e contrastante com a narrativa coerente e minuciosa dos policiais, o que indica que ele se dedicava à mercancia de drogas. A versão por ele apresentada não guarda correspondência com a realidade, porque a narrativa empregada é dissonante do que fora apurado durante a instrução criminal. Os argumentos, portanto, mostram-se inverossímeis, por não encontrar respaldo fático. O que se percebe da versão do acusado é que ele tenta eximir-se da culpa negando a prática do delito. Disse que é apenas usuário, não traficante, mas o que se percebe é o nítido intuito de eximir-se da responsabilização penal, razão pela qual a versão por ele apresentada não pode ser aceita. As circunstâncias demonstram que o acusado guardava a droga apreendida para entrega a consumo de terceiros, conforme descreve a denúncia e narram os Policiais Militares. Verificada a materialidade e a autoria, passo a analisar a adequação típica da conduta praticada pelo acusado. A lei não define o que seja traficância. A tal noção, porém, se chega, ao afastar a hipótese de que a posse da droga se destina para o consumo pessoal. Em outras palavras, pela legislação vigente, haverá

tráfico quando não houver consumo pessoal. A Lei de Drogas estabelece alguns critérios que devem guiar a cognição do juiz no sentido da determinação do significado do fato penalmente relevante, nos termos do artigo 28, parágrafo segundo (natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente). Com o acusado foi apreendido (i) 01 aparelho celular da marca Samsung, (ii) 18 porções de Cocaína, pesando 2g, conforme o laudo pericial definitivo às fls. 150/152, e (iii) a quantia em dinheiro no valor total de R\$ 1.416,00 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais), em diversas notas de R\$ 2,00; R\$ 10,00; R\$ 20,00; R\$ 50,00 e R\$ 100,00. No caso dos autos, portanto, a quantidade de droga apreendida (pequenas quantidades já fracionadas para venda), as circunstâncias da apreensão (reação do Réu, a quantidade de dinheiro em sua posse e a forma de acondicionamento da droga) e as circunstâncias pessoais do réu (responde a processos criminais por tráfico de drogas - fls. 67 - e possui condenação em razão da prática do delito previsto no artigo 12 da Lei nº 6368/76 revogada pela Lei nº 11.343/06), demonstram que era ela (a droga) destinada ao consumo de terceiros, e não próprio. Assim, caracterizado o crime de tráfico. Além disso, foi constatada através de perícia realizada no aparelho celular apreendido (fls. 248/257) uma conversa entre o acusado de alcunha 'veio' e outro indivíduo pelo aplicativo 'whatsapp'. No conteúdo das mensagens, é possível verificar, analisando os termos usados para disfarçar a conduta delitativa, uma possível negociação quanto à compra e venda de entorpecentes, configurando o acusado como o vendedor das substâncias. Deve-se ressaltar que, diante da multiplicidade de condutas previstas no art. 33, caput, da Lei de Drogas, não é necessária a comprovação cabal da mercancia, bastando que haja prova da adequação da conduta a qualquer um dos verbos previstos no tipo penal: Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Recurso defensivo buscando a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal ou, subsidiariamente, a redução da pena, afastando-se o aumento de pena em razão de condenação sem trânsito em julgado para o réu, e mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante - Apreensão de 8,98g de cocaína, na forma de crack - Réu que negou a prática delitativa - negativa que não prospera - Policiais Militares que esclareceram as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, que é a certeza visual do crime, bem como da apreensão das drogas. Relataram que, após informação de que o réu retornaria da cidade de Dracena, onde foi comprar drogas para posterior comercialização no Município de Ouro Verde, deslocaram-se até a Rodoviária e aguardaram o retorno dele. Visualizaram o réu descer do ônibus e ele, ao perceber a presença policial, tentou se desfazer da droga. Realizada a abordagem e indagado, o acusado declarou que a droga destinava-se ao seu consumo próprio. A droga foi localizada, e constataram se tratar de uma porção de crack, que não estava fracionada, e não poderia ser consumida naquele estado, sem antes fracioná-la. Réu que é conhecido pela alcunha 'Boliviano', e pela prática de tráfico de drogas, com prisão anterior pela prática do mesmo delito. Droga apreendida com o réu que renderia entre trinta a quarenta porções de crack - Tráfico de drogas consumado - Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas - Prova que demonstrou efetivamente a ocorrência de tráfico de entorpecentes - condenação de rigor, nos termos da denúncia. Dosimetria - Pena-base fundamentadamente exasperada - Sem alteração na segunda e terceira fases. Não cabimento do redutor de pena, por falta de amparo legal Não cabimento de penas restritivas de direitos, por falta de amparo legal Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado no caso concreto. Recurso da Defesa improvido - (TJSP; Apelação Criminal 0001325-64.2018.8.26.0168; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019) (grifos acrescidos). Portanto, o simples fato do acusado, com a finalidade posterior de entregar os entorpecentes para comércio, guardar, manter em depósito, trazer consigo, a substância, também caracteriza o crime em questão. Apenas importante destacar que o fato do Réu ser usuário de drogas não excluiu a

traficância por ele praticada. Na verdade, na maioria das vezes, o tráfico de drogas é praticado justamente para a manutenção do vício. No presente processo, restou cabalmente comprovado que o Réu Emerson Lorenzi, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, tinha em depósito, guardava e transportava substâncias ilícitas destinadas ao tráfico de drogas, praticando os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 33, 'caput', da Lei 11.343/06. Verificada, à vista de todos os elementos dos autos, que o acusado, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 33, 'caput', da lei Antidrogas. Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal. No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude. Além disso, inexistem nos autos qualquer elemento que aponte que ele agiu de forma justificada. Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal. Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o réu sequer suscitou a existência de dirimentes. Apenas é importante destacar que, embora o acusado tenha falado que, no dia

dos fatos, havia consumido álcool e droga, isso não é suficiente para afastar a sua culpabilidade. Nos termos do artigo 28, II, do Código Penal, a simples ingestão de bebida alcoólica ou de substância de efeitos análogos aos do álcool não basta a acarretar a incapacidade do agente, tornando indispensável a demonstração da inimputabilidade daí decorrente, e que a embriaguez era involuntária ou acidental. O réu, como por ele afirmado em juízo, de forma voluntária, fez uso de substância entorpecente e álcool, e a partir de então se propôs à prática dos delitos, de modo que a embriaguez voluntária não se presta a beneficiá-lo, seja para afastar a condenação, seja para reduzir a pena aplicada. Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, porquanto o réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa. Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu Emerson Lorenzi pela prática do crime tipificado no art. 33, 'caput', da lei 11.343/06, e do delito previsto no artigo 329 do Código Penal. Passo à fixação da pena. Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68). Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06 tem-se o seguinte: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes: trata-se de acusado portador de maus antecedentes, em face das condenações com trânsitos em julgado em 20/09/2011 e 01/12/2010, datas anteriores à prática do delito objeto de investigação destes autos, tendo as penas sido cumpridas ou julgadas extintas em 17/08/2016 (cf. certidão de fls. 70/71 e 74), referente aos autos de nº 0021210-87.2007.8.26.0576 e 0064285-79.2007.8.26.0576); c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida dos acusados em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade dos réus, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que

são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: tal circunstância não deverá ser valorada, tendo em vista que não há vítima específica em tal delito; i) Natureza e a quantidade da droga: são normais a espécie. Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 dias de reclusão. Na segunda fase, incide a agravante de reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (cf. certidão de fl. 67, referente ao processo de nº 0000556-40.2016.8.26.0390), não havendo atenuantes a serem valoradas, razão pela qual fixo a pena provisória em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 17 (dezesete) dias de reclusão. Quanto à terceira-fase, não há causas de aumento, entretanto é preciso enfrentar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que pressupõe que 'agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa'. Com relação à exigência de que o agente 'não se dedique às atividades criminosas', percebe-se que a ficha criminal do acusado é extensa e demonstra seu envolvimento com o tráfico de drogas. Recentemente, o Réu respondeu a prática do delito de tráfico de drogas, recebendo a pena privativa de liberdade em regime fechado, cujo trânsito em julgado ocorreu em 15.03.2019, no processo nº 0000556-40.2016.8.26.0390 (fl. 67). O acusado não comprovou possuir ocupação lícita, o que, somado à sua ficha criminal, indica o seu real envolvimento na atividade criminosa de disseminação da droga como meio de seu sustento, inviabilizando a aplicação da mencionada causa de diminuição de pena, que visa beneficiar apenas e, tão somente, o pequeno e eventual traficante. Além disso, as mensagens constatadas pelo laudo pericial do aparelho celular do réu (fls. 248/257) confirmam o seu envolvimento no tráfico não de forma pontual, tendo em vista que é possível verificar, analisando os termos usados para disfarçar a conduta delitiva, uma possível negociação quanto à compra e venda de entorpecentes, configurando o acusado, de alcunha 'veio', como o vendedor das substâncias. Por esses motivos, afasto a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, razão pela qual fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 17 (dezesete) dias de reclusão e ao pagamento de 656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias-multa. Nos termos do artigo 60 e 49, parágrafo primeiro, ambos do Código Penal, o valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu. Não se desconhece do entendimento do Supremo Tribunal Federal de que são inconstitucionais as previsões da Lei nº 11.343/06 que impõem a adoção obrigatória do regime inicial fechado para cumprimento da pena dos crimes de tráfico. Entretanto, é possível ao magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo. No caso em apreço, o acusado já ostenta relação pretérita com condenação em outro processo pelo tráfico de drogas (nº 0000556-40.2016.8.26.0390 - fl. 67). Tudo isso demonstra, somada a quantidade da pena imposta, a necessidade de imposição de um regime mais gravoso. Sendo assim, com base no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude da pena aqui aplicada superar 4 anos, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Incabível, também, a suspensão condicional da pena, nos termos do caput do art. 77 do Código Penal. Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR EMERSON LORENZI, já qualificado, pela prática do crime previsto no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 17 (dezesete) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime fechado e ao pagamento de 656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias-multa, no valor individual de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. O acusado ÉMERSON LORENZI encontra-se preso por este processo e, conforme a determinação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, não concedo a ele o direito de recorrer em liberdade em relação aos fatos aqui apurados, uma vez que a permanência dele no cárcere é necessária para a manutenção da ordem pública, eis que já foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo considerado reincidente. Nos termos do

artigo 312 do Código de Processo Penal, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime atribuído ao réu. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, do risco concreto de ele voltar a delinquir, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se afastará do distrito da culpa. Cabe ressaltar, conforme decisões de fls. 171/176 e 293/295, que no caso concreto, o risco à ordem pública é verificado a partir da análise da folha de antecedentes do acusado (fls. 76/120) e da certidão criminal (fls. 67/75), nas quais há registros de passagens do preso por condutas semelhantes, indicando possível reiteração criminosa. O acusado possui condenação anterior transitada em julgado, inclusive pelo mesmo crime de tráfico de entorpecentes, qual seja: processo nº. 000556-40.2016.8.26.0390, condenado à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, em regime inicial fechado (fls. 67). Conclui-se que as demais medidas cautelares são insuficientes, pois a reiteração é indicativa de que a permanência em liberdade não é capaz de inibir a continuação de práticas aparentemente delituosas. Em casos semelhantes, o TJSP se posicionou nesse sentido: PENAL. "HABEAS CORPUS". FURTO QUALIFICADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. Pretendida a revogação da prisão, mediante medidas cautelares alternativas, com expedição de contramandado de prisão; b) seja determinada a juntada de folha de antecedentes criminais Descabimento, na parte conhecida. A) A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista presentes os requisitos legais (artigo 313, I, do Código de Processo Penal). Paciente que, segundo a denúncia, teria praticado, em concurso de agentes, pelo menos três furtos, com o mesmo "modus operandi", inclusive com apreensão de objetos que seriam, em tese, utilizados para a prática dos crimes em questão. Verificada situação de gravidade pelo risco à ordem social que pode ensejar a sua libertação (viabilidade de reiteração), evidenciada que ficou a sua periculosidade pelo "modus operandi" empregado, com a necessidade, então, de se garantir a ordem pública, portanto, com o encarceramento provisório, não surgindo suficiente outra cautelar menos rigorosa. B) Decisão de conversão que se limita a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com observação da gravidade da conduta e periculosidade presumida do agente, de acordo com a necessidade da garantia da ordem pública, afastando, como possível, concessão de liberdade provisória. Constrangimento ilegal não configurado. C) Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, não aplicada à espécie, por não comprovada qualquer situação excepcional a justificar a medida. Ordem, na parte conhecida denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2035303-12.2021.8.26.0000; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/05/2021; Data de Registro: 28/05/2021) (grifos acrescidos). Habeas corpus Paciente preso em flagrante na posse de arma de fogo com numeração suprimida Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, estando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Cód. de Proc. Penal Paciente reincidente em crime patrimonial Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas Inexistência de coação ilegal Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2057125-57.2021.8.26.0000; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2021; Data de Registro: 30/04/2021) (grifos acrescidos). Portanto, recomende-se ao cárcere em que se encontra. Diante da inexistência de pedido expresso na denúncia e ausência de comprovação dos prejuízos causados pela infração, deixo de fixar valor mínimo a título de reparação na forma do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. Com o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, encaminhando-se ao juízo das execuções criminais. DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (art. 72, da Lei nº 11.343/2006), caso a providência já não tenha sido adotada. Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores e bens apreendidos em razão do tráfico de drogas serão

perdidos em favor da União, decreto o perdimento do valor apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis. Ante o Habeas Corpus impetrado (fls. 339-341), oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça para conhecimento deste pronunciamento, em complemento as informações prestadas anteriormente às fls. 342-343. Custas na forma da lei. Com o trânsito em julgado, oficie-se conforme o necessário, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal. A representante do Ministério Público manifestou seu desejo em NÃO recorrer da presente sentença conforme manifestado em audiência. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se.". Nada mais. Eu, José Antonio Vazquez Castro Junior, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Dra. Promotora:

Dr. Defensor:

Réu: